

刑法
No246

共通問題 H28-6

(配点：4)

月 日

月 日

住居を侵す罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

ア. 強盗の意図を隠してA方の玄関前で「こんばんは。」と言ったところ、来客と勘違いしたAから「どうぞお入りください。」と言われてA方住居に立ち入った場合、住居侵入罪が成立する。

イ. 建造物への立入りが平穩な態様で行われた場合には、管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を積極的に明示していない限り、建造物侵入罪が成立することはない。

ウ. 平穩を害する態様での住居への立入りであっても、住居権者の同意に基づくものである場合には、住居侵入罪の構成要件には該当するが、違法性が阻却される。

エ. 現金自動預払機が設置されている銀行支店出張所は、一般の利用客の立入りが許容されている場所であるので、同機を利用する客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で立ち入っても、平穩な態様での立入りであれば、建造物侵入罪が成立することはない。

オ. 住居権者の意思に反して住居に立ち入った上、その後、退去を求められたにもかかわらず数日間にわたってその住居に滞留した場合には、住居侵入罪だけでなく、不退去罪も成立する。

No246

住居を侵す罪

正答率

52%

共通H28-6

正解

ア 1

イ 2

ウ 2

エ 2

オ 2

ア 正しい

最大判昭24.7.22は、住居侵入罪（130条前段）の成立を肯定している。理由として、「強盗の意図を隠して『今晚は』と挨拶し、家人が『おはいり』と答えたのに応じて住居にはいった場合には、外見上家人の承諾があったように見えても、真実においてはその承諾を欠くものであることは、言うまでもないことである」ということを挙げる。よって、強盗の意図を隠してA方の玄関前で「こんばんは。」と言ったところ、来客と勘違いしたAから「どうぞお入りください。」と言われてA方住居に立ち入った場合、住居侵入罪が成立する。

イ 誤っている

最判昭58.4.8（百選Ⅱ16事件）は、管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合でも、建造物侵入罪の成立を肯定している。理由として、「刑法130条前段にいう『侵入し』とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきであるから、管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、同条の罪の成立を免れないというべきである」ということを挙げる。管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合でも、客観的にみて現に行われた立入り行為が管理権者が容認していないと合理的に判断される場合は、建造物侵入罪が成立する。

ウ 誤っている

最判平20.4.11（重判平20刑8事件）は、「刑法130条前段にいう『侵入し』とは、他人の看守する邸宅等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうものである」としており、現在においては、住居権説・管理権説の立場をとることを明確にしている。よって、住居権者の同意に基づく住居への立入りである場合は、立入りの態様が平穏を害していても、「侵入」には当たらず、住居侵入罪の構成要件に該当しない。

エ 誤っている

最決平19.7.2（百選Ⅱ18事件）は、「現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入ったものであり、そのような立入りが同所の管理権者である銀行支店長の意思に反するものであることは明らかであるから、その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客のそれと特に異なるものでなくても、建造物侵入罪が成立する」としている。よって、現金自動預払機を利用する客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的でそれが設置されている銀行支店出張所に立ち入れば、平穏な態様での立入りであっても、建造物侵入罪が成立する。

オ 誤っている ★

最決昭31.8.22は、住居侵入罪の成立のみを肯定し、不退去罪（130条後段）成立を否定している。理由として、「建造物侵入罪は故なく建造物に侵入した場合に成立し退去するまで継続する犯罪であるから、同罪の成立する以上退去しない場合においても不退去罪は成立しないものと解するを相当とする」ということを挙げている。